

1512830-32.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1512830-32.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512830-32.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2253563/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 20302909 - 03º D.P. AMERICANA, 1394/21/346 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RENAN LUIS DAMIAO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

RENAN LUIS DAMIÃO DA SILVA está sendo processado como incurso nas sanções dos artigos 33, 'caput' da Lei 11.343/06, acusado de no dia 16 de setembro de 2021, por volta de 16h25, na Rua das Violetas com a Rua do Azulão, 994, bairro Jardim dos Lírios, nesta cidade, vender por R\$ 8,50 para D.J.S. um invólucro plástico de cocaína, com peso de 0,3 g, bem como trazer com ele dezesseis invólucros plásticos de cocaína, com peso de 4,1 g, além da quantia de R\$ 63,50, drogas que provocam dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia em 18 de novembro de 2021, fls. 134/135, o réu foi citado (fls. 155).

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação.

Na instrução foi inquirida uma testemunha comum e o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 188/192 e 196/200).

A Defesa requer a absolvição por falta de provas. O acusado seria usuário de entorpecentes e foi até o ponto de drogas com Décio, onde adquiriram dois quites de drogas, contendo dezesseis pedras de crack. A droga seria partilhada, para uso coletivo (dividiriam em um grupo de cinco amigos), com a finalidade recreativa. No momento em que dividiam as drogas, apareceu a viatura. O acusado tentou engolir algumas pedras sem êxito, devolvendo-as ao bolso. A pessoa que estava vendendo as drogas se evadiu do local. Invoca o 'in dubio pro reo'. Alternativamente, descCLASSIFICAÇÃO para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Para o caso de condenação, pena mínima, com reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo, pela primariedade. Faria jus à substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso em liberdade, com expedição do competente alvará de soltura (fls. 201/204).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Verifica-se dos autos que o réu foi preso em flagrante delito e na fase administrativa permaneceu em silêncio.

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lanço aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não se reservar para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

No interrogatório judicial, alegou que estava em sua casa, juntamente com o Décio e outras pessoas. Reuniram-se para comprar drogas para consumir. O ponto de drogas ficava na rua da sua casa, onde compraram os entorpecentes. Enquanto dividiam as drogas, a viatura 'virou' na rua debaixo. O vendedor correu, enquanto era abordado pelo guarda municipal. O policial encontrou as drogas no seu bolso.

Ficou assustado, não sabia o que fazer com as drogas e tentou engolir os entorpecentes, mas não conseguiu. Devolveu as drogas ao bolso e logo em seguida foi levado para o Pronto Socorro, onde passou por procedimento. Após, foi levado juntamente com o Décio para a Delegacia. A droga era destinada para uso pessoal e coletivo, pois juntaram cinco pessoas para comprar os entorpecentes. Foi abordado quando dividia a droga com o Décio. Era viciado em drogas. Foi internado uma vez. Não tinha intenção de comercializar drogas. Havia juntado um grupo, consumiriam os entorpecentes em coletivo. Pegaram dois kits, contendo dezesseis pedras cada, totalizando trinta e duas pedras. Cada um ficaria com metade, mas a droga seria para esse uso coletivo. Não tinham a finalidade de venda, tanto que a droga foi encontrada no bolso.

A versão não convence.

O guarda municipal Cleiton José Mariote Lopes esclareceu que estavam em patrulhamento quando avistaram Renan entregando um objeto para outro rapaz. Em troca, ele pegou dinheiro. Ao visualizar a equipe, o acusado colocou algo na boca. O réu foi abordado e revistado. Com ele, localizaram R\$ 63,50 e dezesseis porções de pedras em seu bolso. Questionado sobre o que ele havia colocado em sua boca, Renan respondeu que engoliu quatro porções de crack. Com o outro rapaz, encontraram

uma porção idêntica de crack. Indagado, o outro homem informou que havia comprado uma pedra pelo valor de R\$ 8,50. Diante dos fatos, Renan foi levado até o Hospital Municipal para passar por atendimento médico, devido a ingestão das drogas. Em seguida, os abordados foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária, onde Renan foi autuado em flagrante, enquanto o outro suspeito foi liberado pelo Delegado.

As circunstâncias, assim, não se enquadram ao que o acusado tentou retratar em juízo.

O réu foi visto em atitude típica de venda de drogas. Entregava algo e recebia dinheiro. Avistando os policiais, engoliu quatro porções de drogas e, sem conseguir engolir tudo, voltou ao bolso outras dezesseis porções. Também foi abordado o suspeito da aquisição, Décio, que confirmou a compra da droga, do réu, por R\$8,50. O local era conhecido pelos guardas como ponto de tráfico.

Assim, não foi gratuita a abordagem e muito menos logrou o réu provar que a droga que trazia seria para uso dele e de outras pessoas, ônus que lhe incumbia.

O que se tem de certo e provado é que ele tinha expressiva quantidade de drogas para a ocasião (16 porções), além de numerário de procedência ilícita, na medida em que Décio confirmou ter entregado aquele dinheiro em pagamento da compra de uma porção, sem olvidar as outras quatro porções que o réu ousou engolir.

A quantidade e disposição, não permite inferir conclusão outra senão a de que se destinassem ao tráfico.

A prova, pois, é segura e convincente quanto a responsabilidade criminal do acusado.

Relembre-se que a alegação de que a droga seria para uso próprio e coletivo não foi provada e muito menos é crível, pela citada forma em que estavam embaladas e quantidade, local onde o réu se mantinha, crescendo-se o dinheiro localizado.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao inculpatado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

Também:

"Quem invoca um álibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (TJSP, AP. 53.726, Rel. Azevedo Franceschini).

A conduta é mesmo a de tráfico, não sendo necessário, para a hipótese, que o réu estivesse vendendo drogas. Aqui, excepcionalmente, o réu foi visto vendendo o entorpecente (uma porção), a par de trazer com ele outras dezesseis porções, igualmente para a venda.

Ainda assim, trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput,

da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Também o fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico.

A prova, por isso, é boa e suficiente, com prisão em flagrante delito, certeza visual do delito, apreensão da droga, dinheiro e depoimentos de Guardas civis.

A versão dos guardas municipais, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Por evidente, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato e em que é irrelevante a quantidade da substância apreendida (neste sentido, 5ª T. STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, REsp 1.637.113)

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo laudo de constatação (fls. 09/11), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 72/74).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu é primário. Fixo a pena base no mínimo legal, não expressiva a quantidade de drogas para exasperação com fulcro no artigo 42 da Lei de Drogas.

Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Mantenho inalterada a pena base.

Na terceira fase, pela primariedade e não comprovação de que integrasse associação

ou organização criminosa, possível a redução de pena no percentual de dois terços, o que se faz em atenção à quantidade-nocividade de droga apreendida.

É de se impor o regime inicial aberto, pela somatória da pena, reclusiva, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em decorrência da primariedade e as circunstâncias judiciais já destacadas.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: "Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto." HC nº 239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como "pacote anticrime"), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores. Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao "tráfico privilegiado": Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar RENAN LUIS DAMIÃO DA SILVA às penas de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão, regime inicial aberto e cento e sessenta e seis (166) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput' e § 4º, ambos da Lei número 11.343/2006. Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena e mais dez (10) dias-multa, piso.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 45).

Vinculado o numerário apreendido e objetos, com Gustavo, com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Expeça-se alvará de soltura, pela substituição aqui operada, incompatível com a prisão preventiva vigente, facultado recurso em liberdade.

P.I.C.

Americana, 02 de março de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA